

1501954-24.2021.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gisela Ruffo

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/03/2022

... organização criminosa. O chamado tráfico privilegiado, previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas) não deve ser considerado crime de natureza hedionda. STF. Plenário. HC 118533, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 23/06/2016. Na prática, o que muda para o réu condenado por tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da LD)? Podemos apontar três mudanças ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

4ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Alemães, Piracicaba - 13417-901 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501954-24.2021.8.26.0599 - Controle nº 2022/000012

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2346346/2021 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 22059718 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 3660/21/922 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 2346346 - 04º D.P. PIRACICABA, 3660/21/922 - 04º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS GABRIEL GUIMARÃES LIMA

Réu Preso

Aos 22 de março de 2022, às 14:15h, através de videoconferência na aplicação Microsoft Teams, nos moldes do Comunicado CGJ nº 284/2020 em razão da pandemia do coronavírus, realizou-se a presente audiência, sob a presidência da MMª. Juíza de Direito, Dra. Gisela Ruffo, comigo Escrevente ao final nomeado.

Representante do Ministério Público: Dra. FERNANDA GUIMARÃES ROLIM BERRETA - PRESENTE (via videoconferência)

.

Réu: LUCAS GABRIEL GUIMARÃES LIMA - PRESENTE (via videoconferência)

Defensor constituído: Dr. SEBASTIAO ZINSKY - PRESENTE (via videoconferência)

Testemunha comum: GC GLAUCO AGEU DA SILVA - PRESENTE (via videoconferência)

Testemunha comum: GC LUÍS FERNANDO GOMES DA SILVA - PRESENTE (via videoconferência)

Testemunha da Defesa: MARCELO REDSON DA MOTA - AUSENTE

Testemunha da Defesa: CRISTINA MARIA ALVES FIDÉLIS - PRESENTE (via videoconferência)

Testemunha da Defesa: CRISTIANE APARECIDA BUENO PEREIRA - PRESENTE (via videoconferência)

Iniciados os trabalhos, foi colhido o depoimento da testemunha GLAUCO AGEU DA SILVA.

Dada a palavra à Dra. Promotora, por ela foi dito que desistia da oitiva da testemunha GC LUÍS FERNANDO GOMES DA SILVA, o que foi homologado pela MMª. Juíza.

Dada a palavra à Defesa, por ela foi dito que insistia na oitiva da testemunha GC LUÍS FERNANDO GOMES DA SILVA.

Na sequência, foram colhidos os depoimentos das testemunhas GC LUÍS FERNANDO GOMES DA SILVA, CRISTINA MARIA ALVES FIDELIS e CRISTIANE APARECIDA BUENO PEREIRA.

Dada a palavra à Defesa, por ela foi dito que desistia da oitiva da testemunha MARCELO REDSON DA MOTA , o que foi homologado pela MMª. Juíza.

Após, o réu LUCAS GABRIEL GUIMARÃES LIMA foi devidamente interrogado.

O(s) depoimento(s) e o(s) interrogatório(s) foi(foram) captado(s) e gravado(s) em vídeo e a(s) mídias(s) está(ão) disponível(veis) no presente termo, no Sistema SAJ. A seguir, pela MMª. Juíza foi declarada encerrada a instrução, determinando que as partes se manifestassem em alegações finais.

Pela Dra. Promotora de Justiça foi dito o seguinte: "LUCAS GABRIEL GUIMARÃES LIMA, já qualificado nos autos em epígrafe, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, e no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, pelas condutas delituosas descritas na exordial acusatória de fls. 113/115. O processo teve andamento regular. Devidamente notificado (fls. 187), o réu apresentou sua defesa preliminar (fls. 142/157), sendo a denúncia recebida (fls. 163/166). Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e o réu, por fim, interrogado. Em síntese, o necessário. Passa-se à manifestação. A prova produzida impõe a procedência da ação penal. A materialidade delitiva está consubstanciada pelo boletim de ocorrência de fls. 13/20, auto de exibição e apreensão de fls. 21/22, fotografias de fls. 27/28, pelo laudo de exame químico toxicológico definitivo de fls. 104/106 e pela prova oral coligida. A autoria é incontroversa. O guarda municipal Glaucio Ageu da Silva, confirmando suas declarações prestadas na fase investigativa, narrou que estavam a patrulhamento de rotina pela Avenida Dona Francisca, quando visualizaram uma motocicleta, com dois indivíduos, que passaram em alta velocidade, com a lanterna traseira apagada, sendo que o garupa olhava toda hora para trás, fatos que chamaram a atenção da guarnição. Diante da fundada suspeita, resolveram realizar a abordagem, sendo que com a aproximação da viatura, já na Avenida Presidente Kennedy, foi dada ordem para que o condutor parasse, com sinais sonoros e luminosos acionados, contudo, o condutor da motocicleta acelerou a moto e saiu em fuga, fazendo ziques zagues. Iniciaram o acompanhamento, sendo que o condutor fez o retorno e voltou sentido bairro, neste momento o condutor da moto, jogou uma bolsinha rosa, fato este que foi visualizado pelos guardas de maneira clara e precisa, e continuou na fuga. O condutor da moto, logo a frente, perdeu o controle da motocicleta, vindo a colidir com uma mureta, caindo ambos no chão, tanto o condutor quanto o garupa. Disse que estes indivíduos foram abordados e em revista pessoal nada de ilícito foi localizado. A bolsinha rosa, jogada pelo condutor durante a fuga, foi localizada, próximo a uns 120 metros da abordagem, sendo que em seu interior havia a quantia de 41 micro pinos de cocaína, 107 porções de "crack" e 51 porções de maconha. Os indivíduos foram identificados como sendo o acusado e o garupa como sendo o adolescente. Esclareceu que, devido à queda dos dois durante a fuga, acionaram a equipe de Resgate. No mesmo sentido foram as palavras do guarda municipal Luis Fernando Gomes da Silva, que ressaltou que o acusado e o adolescente que levava na garupa evadiram-se em alta velocidade, olhando toda hora para trás, tendo ainda trafegado em zique zague para evitar o emparelhamento da viatura. Confirmou, ainda, que viram os ocupantes da motocicleta jogar a bolsinha rosa contendo as drogas, as quais foram posteriormente localizadas e apreendidas. As testemunhas de defesa, por sua vez, não presenciaram os fatos e limitaram-se a tecer comentários de cunho pessoal do acusado. A testemunha Cristiane, por sua vez,

confirmou que o acusado não é habilitado para conduzir veículos automotores. Por fim, interrogado, o réu negou os fatos a si atribuídos, alegando que de fato passou ao lado da viatura com a motocicleta que pilotava e, ao fazer a rotatória, reduziu a velocidade, pois viu que a viatura estava atrasada. Alegou que os guardas não deram sinal de parada luminoso ou de sonoro. Disse que caiu da motocicleta no momento em que a viatura encostou na motocicleta e os derrubou. Alegou que não parou porque não era habilitado e a motocicleta não era sua. Os guardas lhe perguntaram porque havia corrido, e disse que era porque não era habilitado, tendo pedido desculpas. Os guardas lhe perguntaram se procurassem se iriam achar algo, e disse que não. Disse que foram socorridos e depois levados na delegacia. Alegou que as drogas não lhe foram apreendidas, e que um dos guardas lhe disse que iriam apresentá-lo por tráfico. Disse que o adolescente que estava consigo se chamava Pablo, e acreditava que ele tinha 19 anos. Alegou que Pablo estava abraçado em sua barriga e não ficou olhando para trás. Não conhecia os guardas anteriormente. Entretanto, em que pese a negativa do réu quanto aos fatos, sua versão não deve prevalecer, vez que dissonante e isolada das demais provas coligidas nos autos, não encontrando nelas qualquer respaldo. De fato, é certo que os guardas municipais foram uníssomos ao afirmar que viram o acusado conduzindo a motocicleta com o farol traseiro apagado e levando o adolescente na garupa, tendo ele se evadido em alta velocidade e inclusive fazendo zigue zagues, fugindo da viatura, bem como que ele, durante a fuga, dispensou os entorpecentes posteriormente apreendidos e somente foi abordado quando perdeu o controle da motocicleta e colidiu contra uma mureta. Vale ressaltar, por oportuno, que os depoimentos prestados pelos guardas são plenamente válidos como meio de prova, se produzidos sob o crivo do contraditório e se estiverem coerentes com as demais provas produzidas, como ocorre no caso em tela. Nesse sentido já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça, nos termos do voto do Ministro Arnaldo Esteves Lima, no julgamento do HC nº 123293/MS, publicado no dia 16/11/2009, do qual se extrai o seguinte trecho: O depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova. Ainda nesse sentido: PROVA - TESTEMUNHA - Depoimento de agentes policiais - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - Análise que se faz em cada caso concreto - Inexistência de dúvida que justifica o decreto condenatório - O testemunho de policiais, que no cumprimento de sua missão atuam na repressão penal, é tão válido como de qualquer outro testemunho - Merecem credibilidade e se de acordo ou conformidade com as demais provas, justificam um decreto condenatório - Entendimento - Precedentes - Recurso parcialmente provido. (Apelação n. 990.08.180251-1 - Birigui - 16ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Newton de Oliveira Neves - 04/05/2010 - 8640 - Unânime). (Grifei). Destarte, tem-se que os crimes descritos na denúncia restaram bem comprovados, sendo a condenação de rigor, sendo certo que as circunstâncias da apreensão, bem como a quantidade e variedade de drogas apreendidas, a forma como estavam embaladas e, por fim, a conduta do acusado de evadir-se em desabalada carreira ao ver a Guarda Municipal comprovam, por si, que os entorpecentes destinavam-se ao comércio ilícito. Da mesma forma, o crime de trânsito também restou bem caracterizado e comprovado, eis que o acusado não era habilitado, conforme confessado pelo acusado, e, ao se evadir em alta velocidade pelas ruas do bairro, gerou ele perigo de dano e risco à incolumidade de terceiros. Quanto à aplicação da reprimenda, a pena-base do crime de tráfico deve ser fixada acima do mínimo legal, haja vista a natureza e a grande quantidade de droga apreendida (41 eppendorfs de cocaína em pó, pesando aproximadamente 9,1g, 108 porções de cocaína na forma de "crack", com peso líquido de 10,5g, e 51 porções de maconha, pesando cerca de 66,8g), consoante o disposto no artigo 59 do Código Penal e no artigo 42 da Lei nº 11.343/06. Na segunda fase, verifica-se que o acusado é duplamente reincidente (autos nº 0000491-97.2016 - fls. 122; e 0001022-52.2017 - fls. 122/123). Na terceira fase, ante a reincidência, inaplicável o art. 33, § 4º da Lei de Drogas. Ademais, restando comprovado o envolvimento do adolescente Pablo Vitor Inacio no crime de tráfico ora apurados,

deve incidir a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas. Ainda na última fase, em razão do concurso material (art. 69 do CP), as penas devem ser somadas. Requeiro, por fim, seja decretado o perdimento da motocicleta Honda/CG Titan 125 KS, cor preta, placa DLE-0245 (Piracicaba/SP), com fulcro nos artigos 61 e 63, ambos da Lei nº 11.343/2006, e no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal. Diante do exposto, o Ministério Público requer e aguarda a procedência da ação, com a condenação do acusado nos termos da denúncia".

Pela Defesa foi dito o seguinte: "EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA RESPEITOSA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PIRACICABA - ESTADO DE SÃO PAULO Processo nº. 1501954-24.2021.8.26.0599 LUCAS GABRIEL GUIMARÃES LIMA, brasileiro, qualificado às fls. 11/12 e 35/36, atualmente recluso no Centro de Detenção Provisória de Piracicaba, cidade e comarca de Piracicaba, por meio de seu advogado infra-assinado, vem, respeitosamente, à ilustre presença de Vossa Excelência, nos termos do art. 403, § 3º do Código de Processo Penal, apresentar; ALEGAÇÕES FINAIS EM FORMA DE MEMORIAIS "Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 20 de dezembro de 2021, por volta das 21h53, na Rua Dom João Bosco, nº 219, bairro Vila Rezende, nesta cidade e comarca de Piracicaba, LUCAS GABRIEL GUIMARÃES LIMA, qualificado às fls. 11/12 e 35/36, previamente ajustado e agindo com unidade de desígnios e envolvendo o adolescente Pablo Vitor Inácio, qualificado às fls. 10 e 29, transportava e trazia consigo, para inequívocos fins de comercialização a terceiros, 41 (quarenta e um) eppendorfs de cocaína em pó, pesando aproximadamente 9,1g (nove gramas e um decigrama), 108 (cento e oito) porções de cocaína na forma de "crack", com peso líquido de 10,5g (dez gramas e cinco decigramas), e 51 (cinquenta e uma) porções de maconha, pesando cerca de 66,8g (sessenta e seis gramas e oito decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 21/22, fotografias de fls. 27/28, laudo de constatação de fls. 31/33 e laudo químico-toxicológico definitivo de fls. 104/106). Consta, outrossim, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, LUCAS GABRIEL GUIMARÃES LIMA, qualificado às fls. 11/12 e 35/36, dirigiu veículo automotor, em via pública, sem a devida habilitação, gerando perigo de dano. Segundo se apurou, guardas municipais estavam em regular patrulhamento pela Rua Dona Francisca, bairro Vila Rezende, ocasião em que avistaram a motocicleta Honda/CG Titan 125 KS, cor preta, placa DLE-0245, passando em alta velocidade e com a lanterna traseira apagada, sendo que o veículo era conduzido pelo denunciado, tendo como garupa o menor infrator Pablo, que a todo momento olhava para trás, monitorando a viatura. Em razão da atitude suspeita, os agentes públicos resolveram realizar a abordagem e, na avenida Presidente Kennedy, deram ordem de parada, porém LUCAS acelerou a motocicleta e empreendeu fuga. Os guardas municipais passaram a acompanhar a motocicleta conduzida pelo denunciado e visualizaram quando este dispensou uma bolsinha rosa e continuou fugindo. Ato contínuo, na Rua Dom João Bosco, altura do numeral 219, LUCAS perdeu o controle da motocicleta e colidiu com uma mureta, tendo ele e o adolescente caído ao solo. Os agentes da lei, então, procederam à abordagem e recuperaram a bolsinha dispensada pelo denunciado, no interior da qual havia os entorpecentes supra descritos. Ao se evadir em alta velocidade pelas ruas do bairro Vila Rezende, é certo que LUCAS, que não possui habilitação para dirigir veículo automotor, gerou perigo de dano e risco à incolumidade de terceiros, demais motoristas e transeuntes. As circunstâncias da apreensão, a quantidade e variedade de drogas apreendidas, a forma que estavam embaladas, bem como a tentativa do denunciado de se esquivar da abordagem da Guarda Municipal, evidenciam que agia em concurso e unidade de desígnios com o menor infrator, envolvendo-o no tráfico e que os entorpecentes se destinavam ao comércio ilícito. " Ante o exposto, o acusado LUCAS GABRIEL GUIMARÃES LIMA foi denunciado, como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, e no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro. QUANDO SE TORNA INÉPCIA A DENÚNCIA. Numa análise preliminar da peça exordial acusatória, tem-se que a mesma é completamente inepta, vez que desobedece ao comando insculpido no art. 41 do Código de Processo Penal, pois claramente deixa de expor todas as circunstâncias do suposto fato criminoso. Código de Processo Penal: Art. 41. A

denúncia ou queixa conterà a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. (destacamos) Isto porque em relação ao acusado LUCAS, a acusação o aponta como traficante (art. 33, caput), entretanto, em momento algum traz narrativa e elementos que sustentem essas afirmações, o que dificulta o exercício da ampla defesa e do contraditório. De forma inaceitável, a denúncia formulada omite ou deixa de indicar diversas informações e circunstâncias que são relevantes, pois apesar de se ter formulado acusação envolvendo os crimes de tráfico, em nenhum momento o parquet narra sequer qual tipo de droga que seria comercializada, nem onde seria o local da comercialização, e muito menos indica ao menos alguma pessoa que teria adquirido as prováveis substâncias proscritas, acima de tudo o averiguado menor de idade afirmou convincentemente que não havia droga nem com o acusado Lucas e muito menos em seu poder. Nesse sentido, ensina o doutrinador Eugênio Pacelli (Curso de Processo Penal, p. 102, 2017) que “Inepta é a acusação que diminui o exercício da ampla defesa, seja pela insuficiência na descrição dos fatos, seja pela ausência de identificação precisa de seus autores.” Na mesma linha de se reconhecer a inépcia da denúncia ante a ausência de cumprimento dos requisitos previstos no art. 41 do CPP, colaciona-se o seguinte julgado do STJ: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DENÚNCIA. INÉPCIA. TRANCAMENTO. 1. É inepta a denúncia que não expõe os fatos imputados ao denunciado que conduziram ao resultado danoso, pena de responsabilização penal objetiva. 2. Recurso provido para trancar a ação penal em relação ao recorrente. (Processo RHC 41205 RJ 2013/0328927-1, Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA Publicação DJe 14/05/2014, Julgamento 6 de Maio de 2014, Relator Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Portanto, diante dos argumentos supramencionados, conclui-se que a r. Denúncia padece de inépcia, merecendo rejeição por este douto Juízo, nos termos do art. 395, I, do CPP. DA FALTA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. Data vênua, inexistente interesse de agir, e por consequência, carece de justa causa a presente ação, pois a apreensão dos entorpecentes não ficou claro quanto o local em que os guardas disseram ter localizado. Sobre o interesse de agir no processo penal, ensina Norberto Avena (Processo Penal, p. 168. 2017): “O interesse de agir concerne à presença dos elementos mínimos que permitam ao juiz, ao refletir sobre o recebimento da denúncia ou queixa, concluir no sentido de que se trata de acusação factível. Tais elementos consistem nos indícios de autoria de que o imputado realmente é autor ou partícipe do fato descrito, bem como na prova da existência do crime imputado. No âmbito da ação penal, este lastro probatório mínimo constitui o fumus boni iuris – aparência do direito à condenação invocado pelo titular da ação penal ao deduzi-la em juízo com vistas a desencadear o jus puniendi do Estado. Ausente a sua demonstração, não será possível ao magistrado verificar a plausibilidade da acusação, devendo, também neste caso, rejeitar a inicial acusatória com fundamento no art. 395, III, do CPP (falta de justa causa para a ação penal).” (destacamos) Destarte, a denúncia também merece rejeição por ausência de justa causa, desta vez com espeque no art. 395, III, do CPP. MÉRITO: A acusação que pesa sobre o réu é completamente improcedente, sendo que o objeto ilícito apreendido não lhe pertencia. Em nenhum momento o réu confirmou que a droga seria de sua propriedade e sim afirmou que nunca viu aquela droga apreendida. Em verdade, o réu está sendo vítima por ter empreendido fuga devido a não portar Carteira de habilitação “Os crimes de tráfico de drogas previstos no art. 33 da Lei de Drogas são punidos exclusivamente a título de dolo, ou seja, deve o agente ter consciência e vontade de praticar qualquer dos núcleos verbais constantes do art. 33, ciente de que o faz sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (destacamos) DOS POSSÍVEIS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA PENA Verificando a situação do denunciado, é possível concluir que o réu é trabalhador como jardineiro e possui residência fixa. Nesse sentido entende o Supremo Tribunal Federal, senão vejamos: EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA FIXADA EM PATAMAR INFERIOR A DOIS ANOS. PEDIDO DE CONCESSÃO DE SURSIS. IMPETRAÇÃO PREJUDICADA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO PARA RECONHECER A POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE

DIREITOS. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou serem inconstitucionais os arts. 33, § 4º, e 44, caput, da Lei n. 11.343/2006, na parte em que vedavam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes (HC 97.256, Rel. Min. Ayres Britto, sessão de julgamento de 1º.9.2010, Informativo/STF 598). (...) 2. Concessão de ofício para reconhecer a possibilidade de se substituir a pena privativa de liberdade aplicada ao Paciente por restritiva de direitos, desde que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos em lei, devendo a análise ser feita pelo juízo do processo de conhecimento ou, se tiver ocorrido o trânsito em julgado, pelo juízo da execução da pena. Ainda no que tange ao entendimento do STF: EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA

INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (INCISO XLVI DO ART. 5º DA CF/88). ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. (...) 3. As penas restritivas de direitos são, em essência, uma alternativa aos efeitos certamente traumáticos, estigmatizantes e onerosos do cárcere. Não é à toa que todas elas são comumente chamadas de penas alternativas, pois essa é mesmo a sua natureza: constituir-se num substitutivo ao encarceramento e suas sequelas. E o fato é que a pena privativa de liberdade corporal não é a única a cumprir a função retributivo-ressocializadora ou restritivo-preventiva da sanção penal. As demais penas também são vocacionadas para esse geminado papel da retribuição-prevenção-ressocialização, e ninguém melhor do que o juiz natural da causa para saber, no caso concreto, qual o tipo alternativo de reprimenda é suficiente para castigar e, ao mesmo tempo, recuperar socialmente o apenado, prevenindo comportamentos do gênero. (...) Assim, ao denunciado deve ser deferida a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme garantida pela lei penal; e ainda, que sua pena seja fixada no mínimo legal pelas circunstâncias já elencadas. Ademais foi sancionada a Lei do tráfico privilegiado para primários e bons antecedentes vejamos; A Lei de Drogas prevê, em seu art. 33, § 4º, a figura do "traficante privilegiado", também chamada de "traficância menor" ou "traficância eventual": Art. 33 (...) § 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. O chamado tráfico privilegiado, previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas) não deve ser considerado crime de natureza hedionda. STF. Plenário. HC 118533, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 23/06/2016. Na prática, o que muda para o réu condenado por tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da LD)? Podemos apontar três mudanças principais: Segundo a posição anterior Não tinha direito à concessão de anistia, graça e indulto. Para a concessão do livramento condicional, o condenado não podia ser reincidente específico em crimes hediondos ou equiparados e teria que cumprir mais de 2/3 da pena. Para que ocorresse a progressão de regime, o condenado deveria cumprir: 2/5 da pena se fosse primário; e 3/5 (três quintos) se fosse reincidente. Conforme o entendimento ATUAL Passa a ter, em tese, direito à concessão de anistia, graça e indulto, desde que cumpridos os demais requisitos. Para a concessão do livramento condicional, o apenado deverá cumprir 1/3 ou 1/2 da pena, a depender do fato de ser ou não reincidente em crime doloso. Para que ocorra a progressão de regime, o condenado deverá cumprir 1/6 da pena. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já entendeu que a primariedade não precisa ser provada pela defesa para a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, pois isso violaria o princípio do "in dubio pro reo". [...] no caso dos autos, as instâncias precedentes recusaram o pedido defensivo de incidência da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 sob o fundamento de inexistir prova da primariedade do acusado. Incorrendo, assim, numa indisfarçável inversão do ônus da prova e, no extremo, na nulificação da máxima que operacionaliza o direito à presunção de não culpabilidade: in dubio pro reo. Preterição, portanto, de um direito constitucionalmente inscrito no âmbito de tutela da liberdade do indivíduo. 3. Ordem parcialmente deferida para, de logo,

reconhecer a incidência da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 e determinar ao Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Campo Grande/MS que refaça, no ponto, a dosimetria da pena.(HC 97.701, 2ª Turma, Rel. Min. Ayres Britto, j. 3-4-2012, DJE de 21-9-2012) Destarte, no presente caso, merece o acusado ser absolvido sumariamente, com fulcro no art. 397, II, do CPP, que trata da absolvição ante a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente. Outrossim, em caso de não acolhimento do pedido de absolvição sumária, que ao final da instrução processual, que seja o acusado absolvido, com fulcro no art. 386, VI do Código de Processo Penal. Assim sendo, as provas são frágeis, no caso em tela não se trata de um criminoso e sim de uma pessoa honesta, trabalhadora, assim se provando beste processo DOS PEDIDOS: DIANTE DO EXPOSTO, requer: 1) A rejeição da denúncia, com fulcro no art. 395, I e III do CPP; 2) Caso o pedido retro não seja acolhido, requer a absolvição sumária do réu LUCAS GABRIEL GUIMARÃES LIMA, com fulcro no art. 397, II, do CPP; 3) Caso o pedido retro não seja acolhido, neste final seja o réu ABSOLVIDO, com fulcro no art. 386, VI, do CPP. 4) a rejeição da denúncia, por todos os fatos arguidos em relação a falta de mandado de busca e apreensão. 5) Absolver o denunciado Silvio Lemos de Almeida Junior, pela ausência de provas de que este concorreu para a prática do crime, nos termos do art. 386, V do CPP. 6) Por necessário, ad argumentum, caso Vossa Excelência entenda pela condenação, pela prática do crime disposto no art. 33 da Lei 11.343/06, sejam observadas as atenuantes da: a) preponderância na fixação da pena, art. 42 da lei de drogas; b) causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, fixando no mínimo legal, convertendo-a em restritiva de direitos, conforme entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal, e que o denunciado possa continuar em liberdade no recurso de apelação até trânsito em julgado em instância superior. Nesses termos, pede deferimento. Piracicaba, 22 de março de 2022. Sebastião Zinsly OAB/SP - 121.136 Flavio Antonio Maestro Assessor Jurídico Habilitado".

A seguir, pela MMª. Juíza foi proferida a Sentença a seguir:

"Vistos.

LUCAS GABRIEL GUIMARÃES LIMA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06, e no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

Consta da denúncia que, no dia 20 de dezembro de 2021, por volta das 21h53, na Rua Dom João Bosco, nº 219, nesta cidade e comarca de Piracicaba, previamente ajustado, agindo em unidade de designios e envolvendo o adolescente P.V.I., transportava e trazia consigo, para inequívocos fins de comercialização a terceiros, 41 (quarenta e um) "ependorfs" de cocaína em pó, pesando aproximadamente 9,1g (nove gramas e um decigrama), 108 (cento e oito) porções de cocaína na forma de "crack", com peso líquido de 10,5g (dez gramas e cinco decigramas), e 51 (cinquenta e uma) porções de maconha, pesando cerca de 66,8g (sessenta e seis gramas e oito decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta, outrossim, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o réu dirigiu veículo automotor, em via pública, sem a devida habilitação, gerando perigo de dano.

Narra a denúncia que guardas municipais estavam em regular patrulhamento pela Rua Dona Francisca, bairro Vila Rezende, ocasião em que avistaram a motocicleta Honda/CG Titan 125 KS, cor preta, placa DLE-0245, passando em alta velocidade e com a lanterna traseira apagada, sendo que o veículo era conduzido pelo acusado, tendo como garupa o menor infrator Pablo, que a todo momento olhava para trás, monitorando a viatura. Em razão da atitude suspeita, os agentes públicos resolveram realizar a abordagem e, na Avenida Presidente Kennedy, deram ordem de parada, porém LUCAS acelerou a motocicleta e empreendeu fuga. Os guardas municipais passaram a acompanhar a motocicleta conduzida pelo acusado e visualizaram quando este dispensou uma bolsinha rosa e continuou fugindo. Ato contínuo, na Rua Dom João Bosco, altura do numeral 219, LUCAS perdeu o controle da motocicleta e colidiu com uma mureta, tendo ele e o adolescente caído ao solo. Os agentes da lei, então, procederam a abordagem e recuperaram a bolsinha dispensada pelo acusado, no interior da qual havia os entorpecentes supra descritos. Ao se evadir em alta

velocidade pelas ruas do bairro Vila Rezende, LUCAS, que não possui habilitação para dirigir veículo automotor, gerou perigo de dano e risco à incolumidade de terceiros, demais motoristas e transeuntes.

O réu foi notificado nos termos do art. 55 da Lei 11.343/06 (fls. 187) e apresentou defesa preliminar acompanhada de documentos (fls. 142/157), seguindo-se a decisão de fls. 163/166, que recebeu a denúncia.

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas na denúncia e duas, pela Defesa. Após, o réu foi interrogado.

As partes apresentaram alegações finais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

1. A prova dos autos é suficiente e segura ao apontar a responsabilidade penal do réu.

1.1. A materialidade do delito de tráfico restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 21/22 e pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 104/106, que trouxe resultado positivo para cocaína e maconha.

A autoria também é certa.

Por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante, o réu negou a prática do crime. Alegou que estava indo dar uma volta de moto, quando viu a viatura e se assustou, porquanto não tinha carteira de habilitação e pegou a moto do irmão, sem a permissão dele. Narrou que bateu a moto, caiu e se lesionou, sendo socorrido pelos bombeiros. Asseverou que não jogou droga nenhuma durante a tentativa de fuga. Disse que não mexia com drogas. Aduziu que os policiais ficaram bravos porque não obedeceu a ordem de parada. Afirmou que os policiais lhe perguntaram se havia jogado algo e negou, mas, mesmo assim, eles continuaram afirmando que havia dispensado uma bolsinha, o que não era verdade. Alegou que nunca se arriscaria a atravessar a cidade com drogas, sabendo que havia um monte de viaturas fazendo ronda.. Disse que um dos policiais afirmou que seria conduzido à delegacia somente para registrar o acidente, enquanto o outro afirmou que seria conduzido porque estava preso. Aduziu que não viu as drogas no local, mas somente na Delegacia de Polícia (fls. 11/12).

Em juízo, afirmou que houve um “peão de moto” na cidade e conduzia sua motocicleta, em meio a outras. Disse que viu a viatura, mas, em momento algum, recebeu ordem de parada. Declarou que os guardas o cercaram e a viatura encostou na moto, momento em que caíram ao chão. Atestou que os guardas perguntaram porque tinha fugido e se tinha dispensado alguma coisa, tendo respondido que fugiu porque não tinha habilitação e nada havia dispensado. Informou que o guarda civil Glauco ficou todo o tempo ao seu lado, conversando. Aduziu que esse guarda falou que o levariam para a UPA e, após, para a Delegacia, para assinar um termo, pois, empreendendo fuga, tinha colocado em risco a sua própria vida e a vida de terceiros. Porém, chegou outro guarda e falou que iriam acusá-lo de tráfico também. Alegou que, no local da abordagem, não lhe mostraram a droga e, só na Delegacia, soube que foi acusado de tráfico. Disse que Pablo estava na sua garupa porque ia no “peão”, mas só o convidou porque achou que ele tinha dezenove anos.

A negativa do réu, contudo, foi infirmada pela prova produzida.

Com efeito, o guarda civil Glauco relatou que estavam em patrulhamento pela Rua Dona Francisca quando se depararam com uma motocicleta com dois indivíduos. Disse que a lanterna traseira estava apagada e não dava para observar o emplacamento. Aduziu que o garupa ficava olhando para trás, o que levantou a suspeita da equipe. Atestou que deram ordem de parada, mas não foi atendida e a moto saiu em alta velocidade. Informou que eles pegaram a Av. Presidente Kennedy e começaram a fazer zigue-zague na via. Afirmou que o motorista dispensou uma bolsa na cor pink. Disse que ele tentou entrar na contramão, bateu na sarjeta e os dois caíram ao solo. Asseverou que, com eles, nada de ilícito foi encontrado. Então, perguntou o que ele tinha dispensado e ele não respondeu. Disse que voltou ao local onde o réu havia dispensado a bolsa e a recuperou, constatando que continha entorpecentes. Afirmou que o réu e o garupa nada falaram sobre a droga, só reclamavam de dor e foram socorridos pelo Resgate.

No mesmo sentido o depoimento do guarda civil Luís Fernando.



É de se asseverar que o simples fato de as testemunhas de acusação serem guardas civis não é o bastante para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas. Não estando impedidos, seus depoimentos serão considerados como o de qualquer testemunha, já que nenhuma razão tinham para falsear a verdade, a não serem cumpridores de seus deveres funcionais.

E "como toda testemunha o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale não pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se tratar de policial" (RJTJESP 125/263). Nesse mesmo sentido: RT 591/313, 612/316 e 654/278.

A prova acusatória consistente em depoimentos de policiais é tão válida quanto outra qualquer, desde que tais testemunhos sejam insuspeitos, sérios e coerentes. Acrescento que a presunção de imparcialidade, retidão e lisura deve ser em favor da autoridade pública, que age no estrito cumprimento do dever legal (cf. RT 738/665). Logo, sequer é razoável supor que guardas municipais transitariam com tamanha quantidade e variedade de entorpecentes para imputar falsamente sua posse a pessoa que sabiam inocente.

Por fim, não houve qualquer ilegalidade na conduta dos guardas municipais, já que, conforme dispõe a lei, qualquer do povo pode efetuar prisão em flagrante delito (art. 301 do Código de Processo Penal). Aliás, seria absurdo imaginar-se que os guardas municipais, informados da prática criminosa, não pudessem tomar providências para fazer cessar a infração, ficando, passivamente, no aguardo da chegada de policiais civis ou militares (cf. Apelação nº 0019493-07.2010.8.26.0068, Rel. Des. CESAR MECCHI MORALES, j. 16.12.14).

De outra banda, as testemunhas Cristiana Maria e Cristiane Aparecida nada esclareceram sobre os fatos, limitando-se a prestar informações sobre os antecedentes e a conduta social do acusado.

Enfim, o fato de os guardas civis terem surpreendido o réu conduzindo uma motocicleta e dispensando uma bolsa que continha o entorpecente, o que não foi infirmado por nenhum elemento de prova, torna certa a autoria.

A quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, a forma como estavam acondicionados, deixam mesmo evidente que a droga se destinava ao comércio ilícito. Sobre a viabilidade desses elementos demonstrarem a destinação comercial dos entorpecentes, cito o seguinte julgado:

"APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Inconformismo defensivo. - Materialidade e autoria comprovadas. Relatos dos policiais que encontraram drogas em posse do réu - Quantidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes que não deixam dúvidas da narcotraficância - Condenação mantida - Penas bem dosadas que não comportam reparo. Recurso desprovido." (TJ-SP: Apelação Criminal nº0038185-16.2007.8.26.0050, 8ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Camilo Léllis, j. 26/04/2012, v.u.).

Impõe-se, portanto, a condenação do réu como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, valendo anotar que, para sua caracterização, não se exige qualquer ato de venda, bastando, como no caso em tela, que o agente transporte ou traga consigo a substância entorpecente.

Por fim, ficou devidamente caracterizada a causa de aumento prevista no artigo 40, VI, da Lei n. 11.343/06, eis que as circunstâncias da apreensão evidenciaram o envolvimento do adolescente P.V.I. na prática do delito.

Ora, os guardas atestaram que o réu conduzia a motocicleta e o adolescente estava na garupa, voltando-se para trás a todo momento para monitorar a viatura, deixando evidente que estava conluiado com o acusado.

1.2 No que concerne ao crime previsto no art. 309 da Lei 9.503/97, restou incontroversa a autoria, porquanto o réu admitiu que conduzia a motocicleta, sem permissão ou habilitação para dirigir.

E os elementos probatórios constantes dos autos comprovam que o réu, ao fugir da polícia, empregou velocidade excessiva e efetuou manobras arriscadas, colocando em risco a vida de outras pessoas que transitavam pelo local e do próprio garupa, tanto que perdeu o controle da motocicleta, colidiu contra a sarjeta e caiu.

Nesse sentido o depoimento dos guardas municipais e do próprio acusado, que confessou a prática do delito.

Caracterizado, pois, o perigo de dano, de rigor a condenação nos termos da denúncia.

2. Passo, pois, à fixação da pena, observando o critério trifásico estatuído no art. 68 do Código Penal.

Atendendo às circunstâncias do art. 59 do Código Penal, observo que o réu é reincidente (fls. 122/125). Essa circunstância, porém, só pode ser considerada na segunda fase de fixação da pena, evitando-se “bis in idem”. Assim, irrelevantes as demais circunstâncias, fixo a pena-base no mínimo legal, cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, no valor unitário mínimo para o tráfico, e, em seis meses de detenção para o delito de conduzir veículo automotor sem habilitação, anotando que descabe a fixação apenas de multa porque houve concurso com crime hediondo.

Na segunda fase de fixação da pena, está presente a agravante da reincidência (autos 0000491-97.2016 e 0001022-52.2017, ambos da 2ª Vara Criminal local- fls. 122/125). De outro lado, o réu confessou espontaneamente a prática do crime de conduzir veículo automotor sem habilitação. Logo, com relação ao tráfico, aumento pena em um quinto, resultando seis anos de reclusão e seiscentos dias-multa, e, com relação ao crime tipificado no art. 309 do CTB, sopesando as circunstâncias agravante e atenuante, nos moldes do art. 67 do Código Penal, aumento a pena de um sexto, resultando, sete meses de detenção.

Prosseguindo, no que tange ao crime de tráfico, presente a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, elevo a pena em um sexto, totalizando sete anos de reclusão e setecentos dias-multa. De outro lado, a reincidência obsta a aplicação do redutor previsto no parágrafo 4º do art. 33 do referido diploma legal.

No que tange ao crime de conduzir veículo automotor sem habilitação, inexistentes causas de aumento ou de redução da pena, torno definitiva a fixada.

Quanto ao regime inicial para cumprimento da pena, em razão da reincidência e por ser o único compatível com a natureza do delito de tráfico, equiparado a hediondo, fixo o fechado para a pena de reclusão e semiaberto para a de detenção.

A fixação do regime inicial fechado está em consonância com diretriz fixada na própria Constituição Federal, que estabeleceu a necessidade de se conferir tratamento mais severo aos casos de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 5º, inciso XLIII).

Não é demais consignar que as nefastas circunstâncias e consequências que o crime de tráfico de entorpecentes causa à sociedade conclamam a fixação do regime mais gravoso, a fim de que se retire o infrator do convívio social, evitando que ele continue a exercer tais atividades ilícitas, viciando pessoas e destruindo famílias.

Nesse sentido os recentes julgados do E. Tribunal de Justiça deste Estado: Apelação nº 0001994-15.2011.8.26.0443, 4ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Luis Soares de Mello, j. 26.06.12, e Apelação nº 0011197-28.2006.8.26.0038, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Roberto Midolla, j. 28.06.12.

Veda-se, por fim, o direito de apelar em liberdade, eis que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a custódia cautelar, a qual não pode ser tornada insubsistente, sobretudo em razão da superveniência de sentença condenatória pela prática de crime equiparado a hediondo.

Nesse sentido já decidiu o E. Tribunal de Justiça: “Conforme já sedimentado nos Tribunais Superiores, o normal daquele que respondeu o processo preso cautelarmente é que assim permaneça ante a superveniência de sentença penal condenatória e diante da inexistência de qualquer elemento que modifique sua situação processual”. (HC nº 0035894-52.2014.8.26.0000, Relator Des. Alex Zilenovski, julgado em 04.08.2014, V.U.).

Confira-se, ainda, recente julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a custódia cautelar” (HC nº 283948/SP, 5ª Turma, Relator Ministro Jorge Mussi, julgado em 06.05.2014, V. U.).

No que tange ao veículo apreendido, observo que não se comprovou sua origem ilícita ou mesmo que o réu o utilizasse habitualmente para prática do crime. Somente se justificaria a perda do bem se o veículo fosse utilizado especifica e habitualmente como instrumento do crime de tráfico de entorpecentes. E, na hipótese, o réu foi abordado enquanto transportava entorpecente, mas não havia qualquer informação de que o veículo era usado para a prática do crime. A propósito, assim já decidiu este E. Tribunal: "Constitui efeito da condenação o confisco 'dos instrumentos do crime' (art. 91, IIm alínea a, do CP), sendo cabível o confisco 'quando o veículo for direta ou indiretamente colocado como instrumento do crime e não quando ocasionalmente esteja ligado à conduta incriminada' (TJRS AC 27.292 REL. JOÃO RICARDO VINHAS). Não havendo comprovação de que o veículo apreendido fosse contínua e habitualmente utilizado no transporte de droga, mas de seu uso esporádico e eventual para essa finalidade, torna-se sem efeito a determinação de perda, em favor do Estado, do veículo (GM/Chevette, demais dados constantes dos autos), ordenando-se a sua devolução ao proprietário, na origem" (TJSP, 13ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal nº 1477889/1-00, Rel. Des. René Ricupero).

Por conseguinte, deixo de decretar seu perdimento.

3. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para condenar o réu LUCAS GABRIEL GUIMARÃES LIMA, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, e no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de sete anos de reclusão, sete meses de detenção e setecentos dias-multa, no valor unitário mínimo legal, fixado o regime fechado para início do cumprimento da pena de reclusão e semiaberto, para a pena de detenção, vedado o direito de apelar em liberdade.

Recomende-se o réu no local onde se encontra recolhido, servindo cópia da presente como ofício, e, após o trânsito em julgado, procedam-se às anotações e comunicações necessárias, arquivando-se os autos.

Autorizo a restituição do veículo apreendido ao proprietário.

Custas na forma da Lei nº 11.608/03.

Publicada em audiência, registre-se, intime-se, comunique-se, expedindo-se o mais necessário".

Pelo(a) Representante do MP foi dito que NÃO DESEJA RECORRER da sentença.

Pelo RÉU foi dito que DESEJA RECORRER da sentença ora proferida.

Pela DEFESA foi dito que DESEJA RECORRER da sentença ora proferida.

Pela MMª. Juíza de Direito, a seguir, foi dito:

"1) Tendo em vista a EXPRESSA RENÚNCIA do(a) Dr(a). Promotor(a), dou a sentença por TRANSITADA EM JULGADO nesta data, para o MINISTÉRIO PÚBLICO.

2) Recebo o recurso interposto.

3) Desde já sai o Defensor intimado do prazo para apresentação das razões de apelação, independentemente de nova intimação, uma vez que trata-se de processo digital e o recurso foi recebido neste momento.

4) Juntadas as razões, dê-se vista ao MP para contrarrazões de recurso.

5) Expeça-se Guia de Recolhimento e Internamento Provisória.

6) Com as razões e contrarrazões de apelação, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça, com as cautelas de praxe, salientando que o termo final da prescrição é 22/03/2034.

Saem os presentes intimados".

CERTIFICO e dou fé que em sendo a audiência realizada virtualmente e havendo sido o presente termo de audiência lido, achado conforme pelas partes e assinado eletronicamente pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Piracicaba/SP, dispensam-se as assinaturas das eventuais testemunhas e vítimas, visto que os depoimentos são gravados em mídia. NADA MAIS. Eu, Diego Ricardo Lopes Cardoso Da Cruz, digitei.

Gisela Ruffo

JUÍZA DE DIREITO

[Assinado eletronicamente]